Gericht:	LG Mannheim 7. Zivilkammer
Entscheidungsname:	Funkstation
Entscheidungsdatum:	10.11.2017
Aktenzeichen:	7 O 28/16
Dokumenttyp:	Urteil
Quelle:	juris
Normen:	§ 9 S 2 Nr 1 PatG, § 139 Abs 1 PatG, § 140a Abs 1 PatG, § 140a Abs 3 PatG, Art 102 Abs 1 AEUV ... mehr

---

Patentverletzung: Kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand gegen Ansprüche des SEP-Patentinhabers wegen Nichteinhaltung von FRAND-Verfahrensobliegenheiten im Rahmen von Lizenzverhandlungen

Leitsatz

1. In Anwendung des vom Unionsgerichtshof in der Rechtssache Huawei / ZTE entwickelten, FRAND-Lizenzbedingungen gewährleistenden Konzepts treffen den SEP-Patentinhaber maßgeblich Informationsobliegenheiten. Insoweit ist bei Unterbreitung des Lizenzvertragsangebots der Angebotsempfänger in die Lage zu versetzen, anhand objektiver Kriterien nachzuvollziehen, warum dieses Angebot - bei objektivierter Betrachtung aus der Perspektive des Patentinhabers - FRAND-Kriterien entspricht. Hierfür sind insbesondere die Lizenzgebühren anzugeben und die Art und Weise ihrer Berechnung transparent zu machen (Transparenzgebot).(Rn.120)

2. Eine dem Transparenzgebot genügende Erläuterung der Lizenzvertragsbedingungen muss ggf. - bei einer entsprechenden Sachlage - intersubjektiv nachvollziehbar aufzeigen, dass die geforderte Lizenzgebührenhöhe FRAND unter dem Gesichtspunkt "non discriminatory" ist. Hierfür sind vom SEP-Patentinhaber jedenfalls belastbare Angaben zu den konkreten anderweitig gewährten Lizenzbedingungen gegenüber Dritten und den Sachgründen einer etwaigen Ungleichbehandlung der Lizenznehmer / Lizenzsucher zu machen.(Rn.130)

3. Zur Nachholung vorprozessual nicht erfüllter (Informations-)Obliegenheiten des SEP-Patentinhabers im Verletzungsrechtsstreit.(Rn.129)

4. Der Urteilstenor zur Feststellung der Schadensersatzverpflichtung unterliegt auch bei geführtem FRAND-Zwangslizenzeinwand grundsätzlich keiner Beschränkung.(Rn.112)

5. Eine inhaltliche Beschränkung des Auskunfts- / Rechnungslegungstenors ist auch bei geführtem FRAND-Zwangslizenzeinwand im Grundsatz nicht veranlasst. Da regelmäßig die relevanten Umstände der Lizenzierung zu FRAND-Bedingungen hochstreitig sind, kann die Erforderlichkeit von Gewinnangaben zur Beurteilung der FRAND-Grenzen und damit auch zur Vorbereitung eines Schadensersatzhöheprozesses nach der Methode der Lizenzanalogie nicht ohne weiteres von vornherein verneint werden.(Rn.110)

Orientierungssatz

Dem SEP-Inhaber ist die transparente Erläuterung der Lizenzvertragsbedingungen unter Angabe konkreter anderweitig gewährten Lizenzbedingungen und den Sachgründen einer etwai-

gen Ungleichbehandlung der Lizenznehmer / Lizenzsucher schon deshalb zumutbar und abzuverlangen, weil ihn im Hinblick auf das kartellrechtliche Diskriminierungsverbot nach Art. 102 Abs. 1, Abs. 2 lit. c AEUV ohnehin eine sekundäre Darlegungslast hinsichtlich einer Gleichbehandlung der Lizenzsucher und die (primäre) Darlegungs- und Beweislast für einen hinreichenden sachlichen Grund einer Ungleichbehandlung treffen.(Rn.130)

Verfahrensgang

anhängig OLG Karlsruhe, kein Datum verfügbar, 6 U 158/17

Tenor

1. Die Beklagte wird verurteilt,

der Klägerin in einer gesonderten und geordneten Aufstellung, hinsichtlich der Angaben zu a und b unter Vorlage von Rechnungen oder Lieferscheinen oder Quittungen, darüber Angaben zu machen, in welchem Umfang sie seit dem 7. April 2007 Funkstationen, die jeweils Folgendes umfassen:

Sendemittel, um über einen Kanal innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne einen Datenblock zu übertragen, der Informationssymbole und Paritätsprüfungssymbole enthält;

Steuermittel, die auf eine Angabe bezüglich einer Reduzierung der Kanalqualität gemäß einem ersten Kriterium mit einer Verringerung der Datensendeleistung reagieren und

die auf eine Angabe innerhalb der vorgegebenen Zeitspanne bezüglich der Zunahme der Kanalqualität entsprechend einem zweiten Kriterium mit einer Erhöhung der Datensendeleistung reagieren,

in der Bundesrepublik Deutschland angeboten, in den Verkehr gebracht oder gebraucht oder zu den genannten Zwecken eingeführt oder besessen hat,

und zwar unter Angabe

a. der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse, sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,

b. der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen, den jeweiligen Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer,

c. der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen, der jeweiligen Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

d. der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet im Falle von Internet-Werbung der Domain, den Zugriffszahlen und den Schaltungszeiträumen;

e. der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht-gewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von ihr zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer

mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist.

2. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu 1. bezeichneten und seit dem 7. April 2007 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

3. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

4. Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.

5. Das Urteil ist für die Klägerin gegen Sicherheitsleistung zu Ziff. 1 in Höhe von 50.000,00 € und zu Ziff. 4 in Höhe von 8.804,40 € vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

1 Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen behaupteter Patentverletzung auf Unterlassung, Rückruf/Entfernung aus den Vertriebswegen, Vernichtung, sowie Auskunft/Rechnungslegung in Anspruch und begehrt Feststellung der Schadensersatzpflicht.

2 Die Klage wird gestützt auf den deutschen Teil des europäischen Patents EP 1 623 511, das sich auf Funkstationen zur Verwendung in einem drahtlosen Kommunikationssystem bezieht (Klagepatent). Die Veröffentlichung der Erteilung des eine Priorität vom 3. Mai 2003 beanspruchenden Klagepatents erfolgte am 7. März 2007. Eine Übersetzung der europäischen Patentschrift ist eingereicht und unter DE 60 2004 005 179 T2 veröffentlicht worden. Das Klagepatent steht in Kraft. Die Beklagte hat Nichtigkeitsklage zum Bundespatentgericht (Az.: 6 Ni 50/16 (EP)) erhoben. Der geltend gemachte unabhängige Anspruch 1 des Klagepatents hat in der Verfahrenssprache folgenden Wortlaut (mit Bezugszeichen):

3 > A radio station (100) comprising transmitter means (110) for transmitting over a channel in a predetermined time period (0 to t_F) a data block comprising information symbols (*I*) and parity check symbols (*C*) and control means (150) responsive to an indication of a reduction in channel quality according to a first criterion for decreasing the data transmit power and responsive to an indication within the predetermined time period of an increase in channel quality according to a second criterion for increasing the data transmit power.

4 Die Klägerin, ein weltweit operierendes und eine Vielzahl von Patenten u.a. auf dem Gebiet der Mobilfunktechnologie haltendes Elektronikunternehmen, ist in dem beim Deutschen Patent- und Markenamt geführten Register als alleinige Inhaberin des Klagepatents eingetragen.

5 Die Beklagte ist die deutsche Tochtergesellschaft der in T. ansässigen „[...]“ Corporation. Sie vertreibt in der Bundesrepublik Deutschland - unter der Marke „[...]“ - UMTS- und LTE-fähige Mobiltelefone, welche das HSUPA-Kommunikationsprotokoll/Schema anwenden können (angegriffene Ausführungsformen).

6 Das UMTS-Netz, in dem auch die angegriffenen Ausführungsformen arbeiten können, beruht seit dem Release 6, durch den das HSUPA-Schema eingeführt wurde, u.a. auf folgenden verpflichtend einzuhaltenden Standards (im Folgenden einheitlich Standard):

7
- ETSI TS 23.002 v6.10.0 (2005-12), Anlage K C2,
- ETSI TS 25.211 v6.10.0 (2009-09), Anlage K C3,
- ETSI TS 25.212 v6.10.0 (2006-12), Anlage K C4,
- ETSI TS 25.213 v6.5.0 (2006-03), Anlage K C5,
- ETSI TS 25.214 v6.11.0 (2006-12), Anlage K C6,
- ETSI TS 25.427 v6.8.0 (2006-12), Anlage K C7.

8 Gemäß Figur 1 des Standard-Dokuments nach Anlage K C5 werden Anwenderdaten von einer Transportebene, wo sie codiert werden, an die physikalische Kanäle DPCCH, DPDCH, HS-DPCCH, E-DPCCH und E-DPDCH weitergegeben und entsprechend codiert. Diese Kanäle bilden einen Datenstrom, der mit „S“ gekennzeichnet ist.

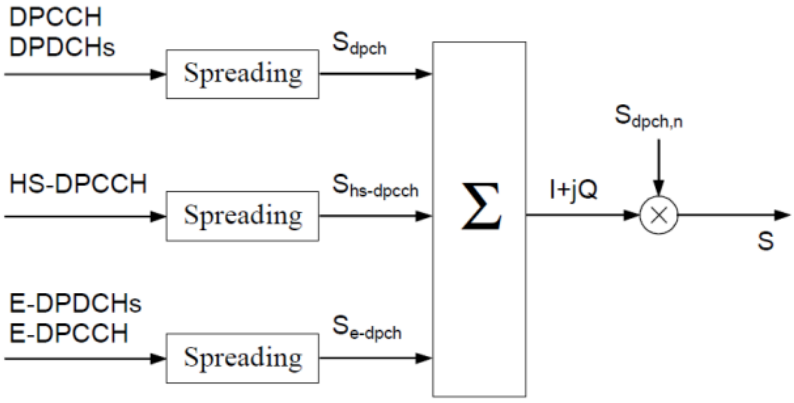

Figure 1: Spreading for uplink dedicated channels

9 Der physikalische Kanal E-DPDCH überträgt dabei Anwenderdaten wie Fotos und Videos und CRC-Daten (vgl. Anlage K C4).

10 Wenn die Kanalqualität abnimmt, wird die Datensendeleistung auf dem E-DPDCH-Kanal verringert. Die Regelung der Sendeleistung vollzieht sich dergestalt, dass die Mobilstation von der Basisstation gesendete TPC-Befehle empfängt. Anhand des TPC-Wertes errechnet die Mobilfunkstation, wie die Übertragungsleistung auf dem Kanal DPCCH anzupassen ist. Der TPC-Befehl hat dabei zunächst unmittelbar nur Auswirkungen auf den Kanal DPCCH. Über sogenannte „gain factors“ wird dann auch die Sendeleistung des E-DPDCH geregelt. Die Version 6 des UMTS-Standards skaliert damit die Sendeleistung des E-DPDCH-Kanals, falls die Gesamtsendeleistung bei Befolgen des TPC-Befehls das maximal zulässige Maß überschreiten würde (Anlage K C6, Abschnitt 5.1.2.6, Seite 26, zweiter Absatz):

When E-DCH is configured, if the total UE transmit power (after applying DPCCH power adjustments and gain factors) would exceed the maximum allowed value, the UE shall firstly reduce all the E-DPDCH gain factors $\beta_{ed,k}$ by an equal scaling factor to respective values $\beta_{ed,k,reduced}$ so that the total transmit power would be equal to the maximum allowed power. After calculating the reduced E-DPDCH gain factors, quantization according to table 1B.2 in [3] subclause 4.2.1.3 may be applied, where each $\beta_{ed,k,reduced}$ is quantized such that $\beta_{ed,k}/\beta_c$ is the largest quantised value for which the condition $\beta_{ed,k} \leq \beta_{ed,k,reduced}$ holds.

11 In entsprechender Weise vollzieht sich die Erhöhung der Datensendeleistung auf dem E-DPDCH-Kanal (vgl. auch ebenda siebter Absatz):

> Any scaling, and any reduction in the E-DPDCH gain factor as described above, shall only be applied or changed at a DPCCH slot boundary. In order that the total UE transmit power does not exceed the maximum allowed value the scaling or E-DPDCH gain factor reduction shall be computed using the maximum HS-DPCCH power transmitted in the next DPCCH slot. In the case that either an ACK or a NACK transmission will start during the next DPCCH slot, the maximum HS-DPCCH power shall be computed using one of the following:
>
> (a) whichever of Δ_{ACK} and Δ_{NACK} will be used according to whether the transmission will be ACK or NACK, *or*
>
> (b) whichever of Δ_{ACK} and Δ_{NACK} is the largest.

12 Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten der sich vollziehenden Abläufe wird auf die zitierten Standarddokumente verwiesen.

13 Zwischen der Klägerin und der Muttergesellschaft der Beklagten wurden bereits vorprozessual Lizenzvertragsverhandlungen geführt. Im November 2013 wies die Klägerin die Muttergesellschaft der Beklagten zunächst schriftlich und unter Beifügung einer Liste der betroffenen Patente darauf hin, dass sie durch den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen UMTS- und LTE-standardessentielle Patente der Klägerin verletze (Anlage K4). Zwischen März 2014 und Juni 2015 kam es zu sieben Treffen zwischen der Klägerin und der Muttergesellschaft der Beklagten, in denen die Klägerin diese aufforderte, für USD […] pro verkaufter Einheit für den „past use“ bzw. USD […] pro verkaufter Einheit in der „compliant rate“ für die Zukunft Lizenz zu nehmen. Die Klägerin verwies auf A, B, C, D und E als weitere Lizenznehmer, ohne deren Vertragskonditionen zu offenbaren, und verglich ihr eigenes Portfolio sowie die Lizenzrate mit der Rate, die von Z gefordert wird. Mit Email vom 21. September 2015 übersendete die Klägerin an die Muttergesellschaft der Beklagten ein Lizenzvertragsangebot mit entsprechenden Konditionen sowie insgesamt 130 Claim-charts, hierunter mit der No. 38 auch ein Claim-chart betreffend das Klagepatent. Am 20. November 2015 kam es zu einem weiteren Treffen zwischen der Klägerin und der Muttergesellschaft der Beklagten, bei dem die Parteien über die kaufmännischen Fragen einer Lizenz verhandelten und in dessen Zuge die Klägerin auf ein im Rahmen einer Auseinandersetzung mit A eingeholtes Sachverständigengutachten, das USD […] pro Patent als Lizenz vorsehe, verwies, welches der Beklagten indes nicht zugänglich gemacht wurde. Im Prozess hat die Beklagte im Namen der „[…]“ Corporation ein Gegenangebot mit Anwaltsschriftsatz vom 8. April 2016 (Anlage TW 4) unterbreitet, das eine Lizenzgebühr von USD […] bezogen auf 89 in Kraft stehenden Patentfamilien für UMTS und LTE vorsieht. Die „[…]“ Computer Inc. hat der Klägerin dementsprechend mit Schreiben vom 6. Juni 2016 Rechnung gelegt und beim Amtsgericht München eine Sicherheit in Höhe von € […] hinterlegt, wobei die nach dem Gegenangebot auf der Grundlage der Rechnungslegung errechneten Lizenzgebühren USD […] betragen. Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten der Lizenzvertragsverhandlungen wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen.

14 Die Klägerin <u>trägt vor</u>,

15 sie sei als Alleininhaberin des Klagepatents aktivlegitimiert. Zwar sei ein 50%-iger Anteil am Klagepatent als Teil des UMTS-Patentportfolios an die […] Corporation ([…]) im Jahr 2007 übertragen worden. Diesen Anteil habe […] allerdings - zugleich unter Abtretung sämtlicher ihr in der Vergangenheit entstandenen Ansprüche aus dem Klagepatent - mit dem „Patent Settlement Agreement“ (PSA) vom 30. September 2015 (teilgeschwärzte Kopie in Anlage K12) auf die Klägerin zurückübertragen. Die Klägerin sei hierbei durch

den unterbevollmächtigten Herrn E. ordnungsgemäß vertreten worden. Für […] habe deren „Executive Officer“ Herr T. als Vertretungsberechtigter gehandelt. […] habe die Vertretungshandlung durch das alleinvertretungsberechtigte Vorstandsmitglied Herrn K. mit Schreiben vom 31. März 2017 (Anlage K25) bestätigt und vorsorglich genehmigt.

16 Sie ist der Auffassung, der Standard sehe eine patentgemäße Sendeleistungssteuerung vor, so dass die angegriffenen Ausführungsformen gemäß Anspruch 1 des Klagepatents ausgebildet seien.

17 Der gegen die danach begründeten Ansprüche erhobene kartellrechtliche Einwand dringe schließlich nicht durch, da die Klägerin die Beklagte insbesondere vor Klageerhebung in ausreichender Weise über die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühr ihres FRAND-Angebots informiert und damit alle den Patentinhaber nach der Entscheidung des Unionsgerichtshofs „Huawei./.ZTE“ treffenden Obliegenheiten bereits vor Klageerhebung erfüllt habe. Hierfür genüge die Mitteilung der verlangten Lizenzgebühr je Einheit, die überdies unter Bezugnahme auf den Wert und die Größe des Patentportfolios erläutert worden sei, sowie die Mitteilung eines Vergleichs mit dem Z-Portfolio sowie der Verweis auf die bestehenden Lizenznehmer A, B, C, D und E und ein Gutachten aus dem A-Verfahren. Jedenfalls sei ausreichend, dass die Klägerin die von der Beklagten vermissten Erläuterungen in ihrer Replik gemacht habe. Zu näheren Erläuterungen sei sie gegenüber der im Grundsatz lizenzunwilligen Beklagten ohnedies nicht verpflichtet gewesen.

18 Die Klägerin **b e a n t r a g t**:

19 1. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000 − ersatzweise Ordnungshaft − oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlungen bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an ihrem jeweiligen Geschäftsführer zu vollstrecken ist, zu unterlassen

20 Funkstationen in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen, wenn die Funkstationen jeweils Folgendes umfassen:

21 Sendemittel, um über einen Kanal innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne einen Datenblock zu übertragen, der Informationssymbole und Paritätsprüfungssymbole enthält;

22 Steuermittel, die auf eine Angabe bezüglich einer Reduzierung der Kanalqualität gemäß einem ersten Kriterium mit einer Verringerung der Datensendeleistung reagieren und

23 die auf eine Angabe innerhalb der vorgegebenen Zeitspanne bezüglich der Zunahme der Kanalqualität entsprechend einem zweiten Kriterium mit einer Erhöhung der Datensendeleistung reagieren;

24 - unabhängiger Anspruch 1 -

25 insbesondere,

26 wenn die Reduzierung der Kanalqualität gemäß dem ersten Kriterium eine Angabe zum Erhöhen der Sendeleistung über einen vorgegebenen Schwellenwert ist;

27 - abhängiger Anspruch 9 -

28 insbesondere,

29 wenn die Angabe zum Erhöhen einer Sendeleistung ein empfangener Befehl ist;

30 - abhängiger Anspruch 10 -

31 insbesondere,

32 wenn die Übertragung des Datenblocks auf einer Vielzahl von Datensignalen gleichzeitig erfolgt, und das Verringern und Erhöhen der Datensendeleistung auf mindestens einem der Datensignale erfolgt;

33 - abhängiger Anspruch 19 -

34 2. Auskunft/Rechnungslegung, wie tenoriert und zusätzlich unter Rückbezug auf „insbesondere-Anträge“ nach Ziff. 1;

35 3. Schadensersatzfeststellung, wie tenoriert und zusätzlich unter Rückbezug auf „insbesondere-Anträge“ nach Ziff. 1;

36 4. Die Beklagte wird verurteilt,

37 a) die vorstehend unter Ziffer 1. bezeichneten, im Besitz Dritter befindlichen und seit dem 7. April 2007 auf den Markt gebrachten Erzeugnisse aus den Vertriebswegen zurückzurufen, indem diejenigen Dritten, denen durch die Beklagte oder mit deren Zustimmung Besitz an den Erzeugnissen eingeräumt wurde, unter Hinweis darauf, dass die Kammer mit dem hiesigen Urteil auf eine Verletzung des Klagepatents DE 60 2004 005 179 (deutscher Teil des EP 1 623 511 B1) erkannt hat, ernsthaft aufgefordert werden, die Erzeugnisse an die Beklagte zurückzugeben und den Dritten für den Fall der Rückgabe der Erzeugnisse eine Rückzahlung des gegebenenfalls bereits gezahlten Kaufpreises sowie die Übernahme der Kosten der Rückgabe zugesagt wird, und endgültig zu entfernen, indem die Beklagte diese Erzeugnisse wieder an sich nimmt oder die Vernichtung derselben beim jeweiligen Besitzer veranlasst,

38 b) die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz und/oder Eigentum befindlichen, vorstehend zu Ziffer 1. bezeichneten Erzeugnisse auf eigene Kosten zu vernichten oder nach ihrer Wahl an einen von ihr zu benennenden Treuhänder zum Zwecke der Vernichtung auf Kosten der Beklagten herauszugeben (alternativ an einen zur Vernichtung bereiten Gerichtsvollzieher).

39 Die Beklagte **b e a n t r a g t**,

40 die Klage abzuweisen;

41 hilfsweise: den Rechtsstreit bis zur rechtskräftigen Erledigung des Nichtigkeitsverfahren auszusetzen.

42 Die Beklagte bringt vor,

43 sie bestreite die vollständige Rückübertragung des Klagepatents auf Grundlage eines wirksamen Übertragungsvertrags, namentlich die Vertretungsbefugnis der Personen, die das PSA unterzeichnet haben. Zudem fehle es dem PSA an der von diesem vorausgesetzten wirksamen Zustimmung der […] B.V. Eine Rückwirkung etwaiger Genehmigungen - insbesondere im Verhältnis zu Dritten wie der Beklagten - käme nicht in Betracht.

44 Eine Benutzung der patentgemäßen Lehre durch die angegriffenen Ausführungsformen, mithin eine Patentverletzung, sei nicht schlüssig dargetan. Die in einem Datenblock nach dem Standard ebenso übermittelten CRC-Bits ermöglichten zwar eine zyklische Redundanzprüfung, dies sei aber nicht dasselbe wie eine Paritätsprüfung, womit die Klägerin im Standard keine „Paritätsprüfungssymbole“ aufgezeigt habe. Ebenso sei im Hinblick auf „eine Angabe bezüglich einer Reduzierung der Kanalqualität“ nicht schlüssig dargetan, dass die von der Klägerin hierzu angeführten TPC-Befehle entsprechende Angaben enthielten, weil diese Befehle nicht zwingend eine Reaktion auf die Qualität gerade dieses Kanals darstellten.

45 Zumindest stehe der Durchsetzung der Unterlassungs-, Rückruf- und Vernichtungsansprüche der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand entgegen. Die Klägerin, welche - dies steht außer Streit, eine ETSI-FRAND-Erklärung abgegeben hat - habe in Bezug auf das Klagepatent eine marktbeherrschende Stellung, weil jedenfalls die im Standard mit dem HSUPA-Schema implementierte Funktionalität für den mobilen Datenverkehr so bedeutsam sei, dass ohne diese für ein Mobiltelefon keine nennenswerten Absatzerfolge mehr erzielt werden könnten. Den sie treffenden Obliegenheiten habe die Klägerin nicht genügt. Sie habe insbesondere vor Klageerhebung trotz Aufforderung nie erläutert, weshalb die von ihr geforderte Stücklizenz FRAND-Bedingungen entspreche.

46 Schließlich werde sich das Klagepatent gegenüber dem Nichtigkeitsangriff nicht behaupten können. Die technische Lehre werde neuheitsschädlich vorweggenommen durch die Entgegenhaltung D1 („Physical Layer Standard für cdma2000 Spread Spectrum Systems - Release 0“), welche in den Niederlanden erstinstanzlich zur Nichtigerklärung des dortigen nationalen Teils geführt hat.

47 Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Parteivortrags wird ergänzend auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie die Sitzungsprotokolle Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

48 Die zulässige Klage ist nur teilweise begründet.

49 Die Klägerin ist als im Register eingetragene Alleininhaberin des Klagepatents prozessführungsbefugt und auch materiell hinsichtlich der erhobenen Ansprüche legitimiert (I.). Da die angegriffenen Ausführungsformen von der Lehre des geltend gemachten, unabhängigen Patentanspruchs 1 (II.) unmittelbar wortsinngemäß Gebrauch machen (III.) und eine Aussetzung des Rechtsstreits nicht angezeigt ist (VI.), ist die Beklagte im beantragten Umfang zu Auskunft und Rechnungslegung zu verurteilen und ihre Schadensersatzverpflichtung festzustellen (IV.). Die auf Unterlassung, Rückruf/Entfernung aus den Vertriebswegen und Vernichtung gerichteten Anträge sind hingegen abzuweisen, weil die

Klägerin insoweit an der Anspruchsdurchsetzung aus kartellrechtlichen Gründen gehindert ist (V.).

I.

50 **Prozessführungsbefugnis und Aktivlegitimation**

51 Die Klägerin ist alleinige im Patentregister eingetragene Inhaberin des Klagepatents und als solche formell zur Prozessführung (Art. 2 Abs. 2, Art. 64 Abs. 1 EPÜ iVm. § 30 Abs. 3 S. 2 PatG) sowie materiell (Art. 64 Abs. 3 EPÜ iVm. §§ 139 ff. PatG) zur Durchsetzung der gegen die Beklagte erhobenen Ansprüche legitimiert.

52 Ihre Sachlegitimation wird durch die Übertragung eines Anteils am Klagepatent an die […] Corporation im Jahre 2007 nicht in Frage gestellt. Denn unter Berücksichtigung des gesamten Inhalts der Verhandlungen steht zur freien Überzeugung der Kammer nach § 286 Abs. 1 ZPO fest, dass dieser Anteil samt in der Vergangenheit dem Mitinhaber entstandener Schadensersatzansprüche gemäß PSA nach Anlage K12 (dort insb. Ziff. 2.1 und Ziff. 2.3) auf die Klägerin zum 30. September 2015 zurückübertragen und dadurch eine zwischenzeitlich bestandene Bruchteilsgemeinschaft am Klagepatent durch Fortfall der Mitberechtigung beendet worden ist.

1.

53 Zwischen den Parteien steht außer Streit, dass der in Kopie nach Anlage K12 als PSA vorgelegte Übertragungsvertrag tatsächlich abgeschlossen wurde, namentlich, dass die Handelnden diesen unterschrieben haben, und dass das PSA das Klagepatent erfasst.

2.

54 Der vorgelegte Übertragungsvertrag ist auch wirksam. Die Bedenken der Beklagten, insbesondere zur Vertretungsbefugnis der handelnden Personen sowie zur Zustimmung der […] B.V., greifen - wie nachstehend (Ziff. 3 - 6) gezeigt - nicht durch.

55 Die Beurteilung der Wirksamkeit des Übertragungsvertrags unterliegt sowohl hinsichtlich der Übertragung des Anteils am Klagepatent als auch hinsichtlich der Abtretung vergangenheitsbezogener Ansprüche aus Patentverletzungen deutschem Sachrecht.

a)

56 Wie die Kammer bereits unter Anschluss an die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Urheberrecht entschieden hat (vgl. InstGE 11, 9 Rn. 13 - UMTS-fähiges Mobiltelefon), unterliegen die Beurteilung von Bestand und Schutz der Rechte am geistigen Eigentum und damit auch die Beurteilung der Wirksamkeit von Verfügungshandlungen der Anknüpfung nach dem Schutzlandprinzip. In Ansehung des Bruchteils am Klagepatent, also des deutschen Teils des europäischen Patents EP 1 623 511, findet hiernach deutsches Sachrecht Anwendung, womit die - vom Verpflichtungsgeschäft zu abstrahierende - Übertragung des Anteils am Klagepatent als Verfügung über das Recht auf das Patent auf §§ 413, 398 BGB (iVm. Art. 2 Abs. 2, Art. 64 Abs. 1 EPÜ iVm. § 15 Abs. 1 S. 2 PatG) beruht.

b)

57 Die Übertragung vergangenheitsbezogener Ansprüche aus Patentverletzungen als Verfügungshandlung hinsichtlich eines Rechts aus dem Patent bestimmt sich nach dem auf das Schutzlandprinzip verweisenden Schuldstatut (Art. 15 lit. e, Art. 8 Abs. 1, Art. 24 Rom-II-VO; Art. 33 Abs. 2 EGBGB), mithin gemäß Art. 64 Abs. 3 EPÜ nach deutschem Sachrecht, womit die Abtretung entsprechender Ansprüche auf § 398 BGB beruht.

3.

58 Anders als die Beklagte meint, bestehen an der Verfügungsberechtigung der […] Corporation keine Zweifel. Vielmehr erachtet die Kammer den klägerischen Vortrag, dass der ursprünglich übertragene Anteil mit dem PSA wieder zurückübertragen worden ist, für wahr. Das Bestreiten der Beklagten mit Nichtwissen in Bezug auf die ursprüngliche Anteilsübertragung an […] und den weiteren Verbleib des Klagepatents bei […] bis zum Abschluss des PSA (Bl. 413 d.A.) erfolgt ohne jeglichen intersubjektiv nachvollziehbaren Anhalt und steht danach einer schlicht spekulativen Andeutung gleich, gegen welche der Umstand der ununterbrochenen und unveränderten Registereintragung der Klägerin als Alleininhaberin des Klagepatents und der auf das „2007 Agreement“ verweisende Inhalt des PSA streiten.

4.

59 Die Klägerin ist bei Abschluss des PSA wirksam gemäß § 164 Abs. 1 S. 1 BGB durch Herrn E. vertreten worden. Herr E. handelte auch innerhalb der ihm zustehenden Vertretungsmacht. Die Klägerin beruft sich insoweit auf eine gewillkürte Stellvertretung im Wege der Unterbevollmächtigung durch den Bevollmächtigten H..

a)

60 Die Klägerin hat durch Vorlage von Handelsregisterauszügen nach Anlagen K13 und K14 samt Übersetzungen sowie durch die Kopie einer Bestätigung des Herrn H. nach Anlage K15 zur Überzeugung der Kammer den Nachweis geführt, dass sie Herrn H. eine übertragbare - die hier in Rede stehenden Geschäfte umfassende - Spezialvollmacht eingeräumt und dass Herr H. Herrn E. zum Abschluss des PSA unterbevollmächtigt hatte. Die Beklagte hat gegen die vorgelegten Anlagen nichts erinnert.

b)

61 Bedenken gegen die rechtliche Wirksamkeit dieser Vollmachten bestehen nicht. Mangels intertemporaler Anwendbarkeit gemäß Art. 229 § 41 EGBGB bestimmt sich das anwendbare Recht nicht nach Art. 8 EGBGB sondern nach den bisherigen, nicht kodifizierten IPR-Grundsätzen zur gewillkürten Stellvertretung. Hiernach sind die Vollmachten mit der herrschenden Meinung zunächst selbständig nach dem Wirkungsstatut anzuknüpfen (vgl. Palandt/Thorn, BGB, 76. Aufl., Anh. zu Art. 10 EGBGB Rn. 2), wobei die Kammer das Wirkungsstatut bei angestellten Bevollmächtigten nach dem Sitz des Vollmachtgebers bestimmt (vgl. mit Nachweis zur bisherigen Rechtslage: Spellenberg in MüKo-BGB, 6. Aufl., Vorbem. zu Art. 11 EGBGB Rn. 133; vgl. zur aktuellen Rechtslage bei fehlender Rechtswahl: Art. 8 Abs. 3 EGBGB), welches vorliegend auf die Niederlande verweist. Anhaltspunkte, dass die Vollmachten nach niederländischem Recht unwirksam sind, sind weder ersichtlich noch werden solche von der Beklagten geltend gemacht.

5.

62 Ob [...] bei Abschluss des PSA durch Herrn T. ordnungsgemäß vertreten worden ist, bedarf keiner Entscheidung. Zumindest ist dessen Vertreterhandeln durch [...] mit Erklärung des Vorstandsmitglieds K. vom 31. März 2017 gegenüber der Klägerin und der [...] B.V. vorsorglich genehmigt worden (Anlage K25: „... and as a matter of precaution I herewith also ratify on behalf of [...] Corporation the signature of Mr. T.“).

a)

63 Die Klägerin hat durch Vorlage eines übersetzten Handelsregisterauszugs nach Anlage K26 nachgewiesen, dass Herrn K. als Vorstandsmitglied von [...] nach dem insoweit maßgeblichen japanischen Gesellschaftsrecht (vgl. zur Anknüpfung der organschaftlichen Vertretungsmacht nach dem Gesellschaftsstatut: Palandt/Thorn aaO Rn. 2) organschaftliche Alleinvertretungsbefugnis für [...] eingeräumt ist. Hiergegen erinnert die Beklagte nichts.

b)

64 Die mit Anlage K25 zur Überzeugung der Kammer belegte vorsorgliche Genehmigungserklärung des Herrn K. hat den infolge eines etwaigen Mangels der Vertretungsmacht des Herrn T. schwebend unwirksamen Übertragungsvertrag mit Rückwirkung auf den Übertragungszeitpunkt wirksam werden lassen.

65 Das anwendbare Recht hinsichtlich der Rechtswirkungen einer Vertretung ohne Vertretungsmacht, namentlich eines Genehmigungsrechts, ist nach dem Geschäftsstatut anzuknüpfen (vgl. Palandt/Thorn aaO Rn. 3). Die hier interessierenden Verfügungsgeschäfte unterliegen - wie ausgeführt - deutschem Sachrecht, so dass ein etwaiger Vertretungsmangel gemäß § 177 Abs. 1, § 184 Abs. 1 BGB durch nachträgliche Zustimmung mit Wirkung ex-tunc geheilt werden kann. Soweit die Beklagte eine rechtliche Rückwirkung unter Verweis auf die Entscheidung BGHZ 70, 299 anzweifelt, übersieht sie, dass Gegenstand dieser Entscheidung des Bundesgerichtshofs ausschließlich die Abtretung vertraglich unabtretbarer Forderungen nach § 399 BGB war, auf welche im Falle des späteren Einverständnisses des Schuldners von vornherein gerade nicht die Bestimmungen nach § 185 Abs. 2, §§ 182, 184 BGB Anwendung finden.

6.

66 Endlich ergibt sich aus dem im PSA begründeten Verpflichtungsgeschäft keine Teilnichtigkeit, die eine Gesamtnichtigkeit des PSA und damit gemäß § 139 BGB eine Nichtigkeit der hier interessierenden Verfügungsgeschäfte nach sich ziehen würde.

a)

67 Soweit in Bezug auf die wirksame Vertretung der Vertragsparteien nach dem Vorstehenden die wirksame Vertretung von [...] durch Herrn T. zweifelhaft wäre, genügt nach dem gemäß Art. 3 Abs. 1 Rom-I-VO iVm. Ziff. 7.7 PSA durch Rechtswahl anwendbaren Recht der Niederlande (vgl. Article 3:69 (i) of the Dutch Civil Code[1]) die Feststellung, dass das Vertreterhandeln durch Erklärung des Vorstandsmitglieds K. vorsorglich genehmigt worden ist.

b)

68 Soweit die Beklagte schließlich moniert, eine nach dem PSA von den Parteien vorausgesetzte wirksame Zustimmung der [...] B.V. fehle, weil die dem handelnden Vertreter Herrn D. nur für Geschäfte im Wert von bis zu 50.000 € eingeräumte Vertretungsmacht überschritten worden sei, dringt auch dies nicht durch. Selbst wenn mit der Beklagten von einem rechtlichen Zustimmungserfordernis der [...] B.V. und hinsichtlich derer von einem Vertretungsmangel auszugehen wäre, hat die Klägerin mit Vorlage der Anlagen K22 und K24 belegt, dass die [...] B.V. - handelnd durch die Vorstandsmitglieder […] - mit Erklärung vom 23. Februar 2017 gegenüber [...] und durch Übermittlung einer Abschrift dieser Erklärung an die Klägerin zur Vorlage im Prozess auch konkludent ihr gegenüber das Vertreterhandeln des Herrn D. vorsorglich genehmigt hat (Anlage K22: „… for the avoidance of doubt, ratify the confirmatory signature [of] Mr. D.“). Eine solch rückwirkende Genehmigung sieht das anwendbare Recht der Niederlande ausdrücklich vor (vgl. Article 3:69 (i) of the Dutch Civil Code, Fn. 1). Dass die in der Erklärung nach Anlage K22 Handelnden gemeinsam organschaftliche Vertretungsmacht haben, unterliegt nach dem vorgelegten Handelsregisterauszug nach Anlage K23a/K23c keinem vernünftigen Zweifel.

II.

69 **Klagepatent**

1.

70 Das Klagepatent betrifft ein Kommunikationssystem mit Funkstationen. Es referiert im Stand der Technik eine Sendeleistungssteuerung, bei der auf eine als unzureichend erkannte Kanalqualität mit einer Erhöhung der Leistung reagiert werde. Diese Anpassung könne in einer offenen oder einer geschlossenen Regelungsschleife erfolgen. Beispielsweise funktioniere ein geschlossener Leistungsregelungskreis in Uplink-Richtung, d.h. von der Mobilstation zum Netz hin, dergestalt, dass die netzwerkseitige Basisstation ein Signal von der Mobilstation empfange und dabei die Qualität des Übertragungskanals überwache. Die Basisstation gleiche sodann die gemessene Qualität des Kanals mit bestimmten Parametern ab und kommuniziere der Mobilstation mittels eines TPC-Befehls, die Sendeleistung entweder zu erhöhen oder zu verringern. Hierauf reagiere die Mobilstation und sende mit entsprechend modifizierter Leistung, die dann wiederum dieselbe Regelungsschleife durchlaufe.

71 Als nachteilig wird an diesem Regelungsmechanismus kritisiert, dass der Sender nicht leistungseffizient arbeite, weil er bei schlechter Kanalqualität stets mit einer Erhöhung des Leistungspegels reagiere. Zudem sei nachteilig, dass eine Erhöhung der Sendeleistung die Gefahr von Interferenzen mit sich bringe, was wiederum die Effizienz der Datenübertragung im Netz, also die gesamte Systemkapazität negativ beeinflusse. Im Stand der Technik sei daher auch bekannt, die Übertragung einer Mobilstation zeitweise auszusetzen, wenn sich die Kanalqualität zu sehr verschlechtere, indem ein Maß der Kanalqualität unter einen vorgegebenen Mindestschwellenwert absinkt, oder wenn eine befohlene Sendeleistung einen vorgegebenen maximalen Schwellenwert übersteigt.

72 Das Klagepatent sieht sich hiernach vor der Aufgabe, die Effizienz der Datenübertragung im Netz zu verbessern.

2.

73 Zur Lösung schlägt das Klagepatent mit seinem unabhängigen Anspruch 1 die Ausgestaltung einer Funkstation mit folgenden Merkmalen vor:

74 a. Funkstation umfassend

75 b. Sendemittel, um

76 b.1 über einen Kanal innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne

77 b.2 einen Datenblock zu übertragen,

78 b.2.1 der Informationssymbole und

b.2.2 Paritätsprüfungssymbole enthält;

79 c. Steuermittel,

80 c.1 die auf eine Angabe bezüglich einer Reduzierung der Kanalqualität

81 c.1.1 gemäß einem ersten Kriterium

c.1.2 mit einer Verringerung der Datensendeleistung reagieren

82 c.2 und die auf eine Angabe innerhalb der vorgegebene Zeitspanne bezüglich einer Zunahme der Kanalqualität

83 c.2.1 gemäß einem zweiten Kriterium

c.2.2 mit einer Erhöhung der Datensendeleistung reagieren.

3.

a)

84 Wie der Durchschnittsfachmann die Kombination der Merkmale des Patentanspruchs versteht, ergibt sich ausgehend vom Patentanspruch (Art. 69 Abs. 1 S. 1 EPÜ) nach dem technischen Zusammenhang seiner Merkmale unter Heranziehung der Beschreibung und Zeichnungen (Art. 69 Abs. 1 S. 2 EPÜ). Durch Heranziehung der Beschreibung zur Auslegung wird sichergestellt, dass der tatsächliche Sprachgebrauch des Patents hinreichende Beachtung findet. Der Fachmann orientiert sich hierbei an dem in der Patentschrift zum Ausdruck gekommenen Zweck der Merkmale, womit der technische Sinn der in der Patentschrift benutzten Worte und Begriffe - nicht die philologische oder logisch-wissenschaftliche Begriffsbestimmung - entscheidend ist, die Patentschrift gleichsam ihr eigenes Lexikon darstellt (vgl. BGHZ 150, 149, 156 - Schneidmesser I; BGH, GRUR 1991, 909 - Spannschraube). Dabei schränken die Ausführungsbeispiele sowie die darauf bezogenen Beschreibungsteile einen weiter zu verstehenden Sinngehalt der Patentansprüche nicht auf diese Ausführungsformen ein. Eine Auslegung unterhalb eines allgemeineren Sinngehalts der Ansprüche ist generell nicht zulässig (vgl. BGHZ 160, 204 - Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung).

b)

85 Nach diesen Grundsätzen ist der geschützten Merkmalskombination - soweit für diesen Rechtsstreit von Interesse - folgender Sinngehalt beizumessen:

86 Die Lehre des Klagepatents sieht zur Effizienzsteigerung vor, eine spezifische Sendeleistungssteuerung durch entsprechende Steuermittel (Merkmalsgruppe c) in einer mit Sendemitteln ausgestatteten Funkstation (Merkmal a und Merkmalsgruppe b) zu implementieren.

aa)

87 Die Steuerung der Datensendeleistung bezieht sich insoweit auf eine blockweise Datenübertragung innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne (Merkmale b.1, b.2), bspw. als Teil einer Rahmenstruktur mit einer Vielzahl derartiger Zeitspannen. Ein Datenblock (Merkmal b.2) enthält Informationssymbole und - im Sprachgebrauch des Klagepatents - Paritätsprüfungssymbole („parity check symbols“). Letztere dienen nach der Patentbeschreibung dazu, beim Übertragungsempfänger fehlerhaft übertragene Daten des Datenblocks, bspw. fehlende Teilbereiche der Informationssymbole, durch Fehlerkorrektur - jedenfalls zu einem gewissen Grad - wiederherstellen zu können (vgl. Abschn. 37, Sp. 8 Z. 35-38; Abschn. 39, Sp. 9 Z. 8-11; Abschn. 41, Sp. 9 Z. 47-48 und Abschn. 52, Sp. 11 Z. 54-55).

88 Paritätsprüfungssymbole nach Merkmal b.2.2 sind danach sämtliche Informationen, die eine Prüfung und Korrektur von Übertragungsfehlern erlauben. Da die Klagepatentschrift keine spezifische Art des Fehlerkorrekturmechanismus beschreibt und auch technisch-funktional kein Grund ersichtlich ist, weshalb die im Kern gelehrte Sendeleistungssteuerung nur eine Datenübertragung im Blick haben sollte, die mit einer speziellen Fehlerkorrekturfähigkeit arbeitet, bestehen keine hinreichenden Anhaltspunkte, dass sich das Klagepatent und seine Ansprüche mit der Begriffswahl „parity check“ auf einen speziellen Fehlerprüfungs- und Korrekturmechanismus festgelegt hätten. Soweit in der allgemeinen Fachsprache unter Paritätsprüfung nur eine spezifische Ausprägung der allgemeinen Fehlerprüfung und -korrektur bei Datenübertragungen verstanden wird, liegt dem Klagepatent ein abweichendes allgemeineres Begriffsverständnis zugrunde.

bb)

89 Die Steuermittel sind für die Sendeleistungssteuerung nach Merkmalen c.1 und c.2 dazu ausgebildet, auf eine Angabe - innerhalb der vorgegebenen Zeitspanne der Datenblockübertragung (vgl. Merkmale b.1 und c.2) - bezüglich einer veränderten Kanalqualität (Reduzierung oder Zunahme) zu reagieren. Unter dem Kanal (Merkmal b.1), auf dessen Qualität die Steuermittel reagieren, versteht das Klagepatent allgemein den Übertragungsweg zwischen den Funkstationen (vgl. Abschn. 21, Sp. 4 Z. 19-29). Dabei ist es ins fachmännische Wissen und Können gestellt, dass der Kanal und die Datenblockübertragung über diesen mit einem oder gleichzeitig mehreren Datensignalen auf verschiedenen „physikalischen Kanälen“ / einer Vielzahl von Trägern organisiert sein kann (vgl. auch Abschn. 2, Sp. 2 Z. 30-37). Die Kanalqualität kann entsprechend unabhängig für jeden Kanalträger einzeln oder deren den Kanal bildenden Vielzahl einheitlich gemessen werden und die damit verbundene Steuerung der Sendeleistung kann den Sendeleistungspegel nur für einen oder mehrere Träger einstellen, wobei sich der Leistungspegel entsprechend auf die Sendeleistung nur eines der Datensignale oder auf die gesamte

kombinierte Sendeleistung / Gesamtsendeleistung einer Vielzahl von Datensignalen bezieht (vgl. auch Abschn. 50, Sp. 11 Z. 34-44; Abschn. 31, Sp. 6 Z. 18-31).

cc)

90 Die Effizienzsteigerung bei der Datenübertragung im Netz verwirklicht das Klagepatent indem die Datensendeleistungssteuerung nach Merkmalsgruppe c nicht allein von den netzwerkseitigen Kanalqualitätsangaben abhängig gemacht wird, sondern die Steuerung zusätzlich weiteren bestimmten Bedingungen, nämlich einem ersten (Merkmal c.1.1) und einem zweiten Kriterium (Merkmal c.2.1) unterworfen wird.

91 Auf die Angabe reduzierter Kanalqualität wird die Steuerung, anstatt mit einer (weiteren) Leistungserhöhung zu reagieren, die Datensendeleistung absenken (Merkmal c.1.2), wenn aufgrund eines vorbestimmten ersten Kriteriums eine weitere Erhöhung der Leistung keine verhältnismäßige Gegenmaßnahme zum Kompensieren einer abnehmenden Kanalqualität mehr ist, bspw. wenn ein vorgegebener maximaler (Gesamt-)Sendeleistungspegel erreicht oder ansonsten überschritten würde (vgl. Abschn. 26 und 27). In dieser Situation kann durch diese Maßnahme Energie eingespart und Interferenz reduziert werden (vgl. Abschn. 10).

92 Verbessert sich die Kanalqualität wieder und wird ein zweites Kriterium erfüllt, wird die Steuerung auf eine entsprechende Angabe innerhalb der vorgegebenen Zeitspanne die Sendeleistung (zunächst) wieder erhöhen (Merkmal c.2.2). Das zweite Kriterium legt damit fest, wann die Sendeleistung zunächst zu erhöhen ist und zugleich wann ggf. der Sendeleistungspegel den Änderungen der Kanalqualität - wie im gewürdigten Stand der Technik vorbekannt - wieder vollständig folgen soll (vgl. Abschn. 34). Die patentgemäße Erhöhung der Sendeleistung innerhalb des Übertragungszeitraums des Datenblocks in dieser Situation bei gestiegener Kanalqualität trägt im System letztlich zur Funktionsfähigkeit der Datenblockübertragung trotz zwischenzeitlicher Leistungsbeschränkung bei.

III.

93 **Patentverletzung**

94 Der inländische Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen durch die Beklagte ohne Zustimmung des Patentinhabers verletzt das Klagepatent gemäß Art. 2 Abs. 2, Art. 64 Abs. 1, Abs. 3 EPÜ iVm. § 9 S. 2 Nr. 1 PatG, weil die angegriffenen Ausführungsformen Erzeugnisse sind, welche vom Gegenstand des Klagepatents erfasst werden und hinsichtlich derer das Recht der Klägerin aus dem Klagepatent auch nicht erschöpft ist.

1.

95 Die angegriffenen Ausführungsformen machen von sämtlichen Merkmalen des geltend gemachten Klagepatentanspruchs 1 wortsinngemäß Gebrauch.

a)

96 Dies steht zwischen den Parteien hinsichtlich der Merkmale a, b, b.1, b.2, b.2.1, c, c.1.1, c.1.2, c.2.1 und c.2.2 außer Streit, wobei die übereinstimmende Beurteilung der Parteien nicht auf verfehlten patentrechtlichen Anschauungen beruht.

b)

97 Die angegriffenen Ausführungsformen verwirklichen ebenso Merkmal b.2.2. Die standardgemäße Datenblockübertragung umfasst CRC-Bits (Anlage K C4, Ziffer 4.8.1, Seite 66 und Ziffer 4.2.1, Seite 13), die - dies steht außer Streit - durch „zyklische Redundanzprüfung“ einer Fehlerprüfung zum Zwecke der Übertragungsfehlerkorrektur dienen. Da „Paritätsprüfungssymbole“ im Sinne des Klagepatents - wie ausgeführt - sämtliche Informationen, die eine Prüfung und Korrektur von Übertragungsfehlern erlauben, ohne Einschränkung erfassen, ist es - anders als die Beklagte meint - unerheblich, dass in der Fachwelt die „zyklische Redundanzprüfung“ von einer „Paritätsprüfung“ im engeren Sinne unterschieden wird.

c)

98 Entgegen der Auffassung der Beklagten hat die Klägerin anhand des Standards ebenso schlüssig die Verwirklichung der Merkmale c.1 und c.2 aufgezeigt. Der Einwand der Beklagten, die standardgemäßen TPC-Befehle müssten nicht zwingend eine Reaktion auf die Qualität des E-DPDCH darstellen, bleibt unerheblich. Die im TPC-Befehl mündende Kanalqualität wird zwar allein auf dem DPCH gemessen. Dieses Messergebnis - darauf weist die Klägerin zutreffend hin - steht jedoch stellvertretend für die Übertragungsqualität aller physischen Kanäle, die auf dem Übertragungsweg zur Basisstation den gleichen Problemen ausgesetzt sind. Dieser Übertragungsweg, auf dem im Standard die aus den für die physikalischen Kanäle festgelegten Sendeleistungen kumulierte Gesamtsendeleistung S abgebildet wird, entspricht dem Kanal im Sinne des Klagepatents. Ob die „Gesamtqualität“ des Kanals oder nur die Qualität eines einzelnen Kanalträgers als Referenz der Sendeleistungssteuerung herangezogen wird und ob die Steuerung bei der Sendeleistung nur eines der Datensignale oder bei der Gesamtsendeleistung einer Vielzahl von Datensignalen ansetzt, stellt die technische Lehre des Klagepatentanspruchs - wie aufgezeigt - ins fachmännische Belieben.

d)

99 Soweit die Beklagte ursprünglich die Verwirklichung des Merkmals c.2 weiterhin mit dem Vorbringen in Abrede gestellt hat, der Standard überlasse es dem Belieben der Endgerätehersteller, zu welchem Zeitpunkt die Datensendeleistung auf dem physischen Kanal E-DPDCH wieder angehoben werde, weil der Bezug im Standard auf die Slot-Ebene ausschließlich die Sicherstellung ausreichender Leistungsreserven für die vorrangigen Kanäle vor Augen habe (Bl. 302-314 d.A.), hat die Beklagte mit nachgelassenem Schriftsatz vom 7. September 2017 (Bl. 418 d.A.) den Vortrag der Klägerin zum fachmännischen Verständnis der Vorgaben des Standards an die Gerätehersteller, wonach eine kontinuierliche Anpassung der Stellfaktoren für jeden Slot vorgeschrieben und danach patentgemäß eine Reaktion der Steuermittel „auf eine Angabe innerhalb der vorgegebenen Zeitspanne bezüglich einer Zunahme der Kanalqualität“ vorgesehen werde, unstreitig gestellt.

2.

100 Auf eine Verletzung der mit den Klageanträgen geltend gemachten Unteransprüche 9, 10 und 19 des Klagepatents ist nicht einzugehen, weil die Entscheidung, so genannte „insbesondere“-Anträge in den Urteilstenor aufzunehmen oder nicht, nach der Spruchpraxis der Kammer auf die materielle Reichweite des Tenors keinen Einfluss hat, und es deshalb in ihrem Ermessen steht, ob sie geltend gemachte Merkmale von Unteransprü-

chen zur Konkretisierung des Verletzungsgegenstands mit „insbesondere“ in die Urteilsformel aufnimmt oder nicht (vgl. nur InstGE 12, 200 Rn. 37 - Stickstoffmonoxyd-Nachweis). Die Formulierung nach den Unteransprüchen würde auch vorliegend nichts Wesentliches zu einer exakteren Bestimmung des Tenors beitragen.

3.

101 Eine an den von ihr vertriebenen angegriffenen Ausführungsformen eingetretene Erschöpfung hat die insoweit darlegungs- und beweisbelastete Beklagte nicht erheblich dargetan. Soweit sie im Rahmen ihres FRAND-Lizenz-Vorbringens zur Lizenzgebührenhöhe Vortrag zu den [...]-Chips als Komponenten der angegriffenen Ausführungsformen und dem diesbezüglichen „Subscriber Unit License Agreement“ hält, wird weder aufgezeigt, dass diese Chips selbst die technische Lehre des Klagepatents vollständig realisieren, noch dass diese mit Zustimmung der Patentinhaberin in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht worden sind. Vielmehr meint die Beklagte im Zusammenhang mit der Diskussion der FRAND-Lizenzgebührenhöhe lediglich, dass aufgrund von Lizenzgebühren für [...]-Chips eine Klagepatentnutzung auch ohne Erschöpfung abgegolten sein müsse.

IV.

102 **Schadensersatz und Auskunft / Rechnungslegung**

103 Die festgestellten patentverletzenden Handlungen rechtfertigen nach Maßgabe der nationalen Bestimmungen (Art. 64 Abs. 1, Abs. 3, Art. 2 Abs. 2 EPÜ) die gestellten Anträge, soweit sie auf Auskunftserteilung / Rechnungslegung sowie die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung gerichtet sind.

1.

104 Antragsgemäß ist festzustellen, dass die Beklagte für Handlungen seit 7. April 2007 zum Ersatz des hieraus der Klägerin entstandenen Schadens verpflichtet ist.

105 Die besonderen Zulässigkeitsvoraussetzungen einer Feststellungsklage nach § 256 Abs. 1 ZPO liegen vor. Die Klägerin kennt den genauen Umfang der Verletzungshandlungen nicht. Ohne diese Kenntnis kann sie einen Antrag auf Zahlung von Schadensersatz nicht beziffern. Da aber die Beklagten die Benutzung des Klagepatents und damit die Patentverletzung in Abrede stellen, hat die Klägerin - auch zur Hemmung der Verjährung und Herbeiführung der dreißigjährigen Verjährungsfrist - ein rechtliches Interesse daran, dass das Bestehen eines Ersatzanspruchs alsbald festgestellt wird.

106 Der Anspruch auf Schadensersatz ergibt sich aus § 139 Abs. 2 PatG. Die Beklagte hat schuldhaft, nämlich zumindest fahrlässig gehandelt. Bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt (§ 276 Abs. 2 BGB) hätte im Geschäftsbetrieb der Beklagten spätestens einen Monat nach Veröffentlichung der Mitteilung über die Erteilung des Klagepatents grundsätzlich erkannt werden können und müssen, dass das Klagepatent durch den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen verletzt wird.

2.

107 Die Beklagte ist der Klägerin ferner zur Auskunft und Rechnungslegung - grundsätzlich im beantragten Umfang - verpflichtet gemäß § 140b Abs. 1, Abs. 3 PatG und einer zu Gewohnheitsrecht erstarkten Anwendung von § 242 BGB, wobei die Klägerin Belegvorlage im beantragten und zuerkannten Umfang entsprechend § 259 BGB fordern kann (vgl. zur Belegvorlage: OLG Karlsruhe, InstGE 11, 15 - SMD-Widerstand).

3.

108 Der Urteilsausspruch zu den insoweit beschiedenen Anträgen unterliegt keiner Beschränkung im Hinblick auf den von der Beklagten erhobenen kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand und die ETSI-FRAND-Erklärung der Klägerin. Die Beklagte hat zu Recht in Bezug auf diese Anträge auch keine inhaltlichen Einwände vorgebracht.

a)

109 Die Durchsetzbarkeit der Ansprüche auf Auskunft / Rechnungslegung sowie Schadensersatz dem Grunde nach bleibt auch bei einem erfolgreichen kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand unberührt (vgl. Huawei Technologies/ZTE: EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015 – C-170/13, GRUR 2015, 764 Rn. 72 ff. = ECLI:EU:C:2015:477 idF des Berichtigungsbeschlusses vom 15. Dezember 2015, ECLI:EU:C:2015:817; OLG Düsseldorf, Urteil vom 30. März 2017 - I-15 U 66/15, Rn. 226 - juris).

b)

110 Es kann im Rahmen der allein zu bescheidenden Feststellung der Schadensersatzpflicht (dem Grunde nach) dahinstehen, ob in der konkreten Fallkonstellation der Schadensersatz der Höhe nach - insbesondere für sämtliche in Betracht zu ziehenden Zeiträume - tatsächlich auf dasjenige beschränkt ist, was sich in Anwendung der Schadensausgleichsmethodik „Lizenzanalogie“ auf Basis einer FRAND-Lizenzgebühr ergibt (anders wohl: OLG Düsseldorf aaO Rn. 236). Denn für den Erfolg des Klagebegehrens genügt es festzustellen, dass aufgrund der patentverletzenden Handlungen überhaupt ein Schaden wahrscheinlich entstanden ist, ohne dass Feststellungen zu dessen Höhe geboten sind.

c)

111 Anders als das Oberlandesgericht Düsseldorf in seiner Entscheidung vom 30. März 2017 (aaO Rn. 243 ff.) vertritt, ist eine inhaltliche Beschränkung des Auskunfts- / Rechnungslegungstenors nach Auffassung der Kammer im Grundsatz ebenso wenig veranlasst. Hierbei kann wiederum dahinstehen, ob der Verletzte beim Schadensersatz der Höhe nach auf eine FRAND-Lizenzgebühr beschränkt ist, namentlich also nicht nach der Methode „Verletzergewinn“ seinen Schaden liquidieren kann. Denn selbst bei einer Beschränkung des Schadensersatzanspruchs kann der Verletzte in der hiesigen Konstellation die vorliegend geforderten Daten im Rahmen der Rechnungslegung fordern.

aa)

112 Die Namens-, Anschriften-, Mengen- und Preisangaben nach lit. a und b des Tenors sowie die Einkaufspreise im Rahmen der Gestehungskosten nach lit. e des Tenors schuldet der Verletzer schon im Wege der Auskunft über Herkunft und Vertriebswege nach § 140 Abs. 3 PatG, um dem Verletzten die Wahrnehmung seiner Rechte gegenüber weiteren Verletzern in der Lieferkette zu ermöglichen. Die Auflistung der Einzellieferungen

unter Angabe der Lieferzeiten nach lit. b des Tenors sowie die Angaben zu Angeboten und Werbung nach lit. c und d des Tenors kann der Verletzte zudem bereits unter dem Gesichtspunkt der Plausibilisierung und Nachprüfung der sonstigen Rechnungslegungsangaben im Rahmen von § 242 BGB verlangen; insoweit nimmt auch das Oberlandesgericht Düsseldorf (aaO) keine Beschränkung des Rechnungslegungstenors vor.

bb)

113 Nach Auffassung der Kammer hindert eine mögliche Beschränkung des Schadensersatzes auf Zahlung einer FRAND-Lizenzgebühr nicht, dem Verletzten im Rahmen der Rechnungslegung weitergehend auch Gewinnangaben, letztlich also Angaben zu den zurechenbaren Gestehungskosten, namentlich solche, die über die ohnehin nach § 140b Abs. 3 Nr. 2 PatG gebotenen Einkaufspreisangaben hinausgehen, zuzuerkennen.

114 Zwar sind diese Angaben nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. BGHZ 107, 161, 169 - Offenend-Spinnmaschine; BGHZ 176, 311 Rn. 33 - Tintenpatrone; BGHZ 183, 182 - Türinnenverstärkung), der die Kammer folgt, zur Bemessung des Ersatzanspruchs im Wege der Lizenzanalogie „im Regelfall nicht erforderlich“, weshalb diese Angaben bei der Rechnungslegung zur Vorbereitung und Durchsetzung eines solchen Ersatzanspruchs nach § 242 BGB grundsätzlich nicht geschuldet sind (insoweit auch zutreffend OLG Düsseldorf aaO). Indes ist nach diesen Grundsätzen gerade nicht ausgeschlossen, dass solche Angaben im Sonderfall erforderlich sein können, zumal der Bundesgerichtshof grundsätzlich die mögliche Relevanz des beim Verletzer erwirtschafteten Gewinns für die Bestimmung der Lizenzgebühr anerkennt, insbesondere als die übliche Umsatzrendite bei der Lizenzanalogie berücksichtigungsfähig sein kann (vgl. zu letzterem: BGH, GRUR 2010, 239, 243 - BTK). In Fallkonstellationen wie der vorliegenden, in denen eine Beschränkung des Schadensersatzes auf eine FRAND-Lizenzgebühr in Betracht zu ziehen wäre, allerdings ein am Markt etabliertes Lizenzsystem, welches FRAND-Anforderungen unstreitig oder nachweislich genügt, nicht feststellbar, insbesondere nicht vorgetragen ist und die Parteien vielmehr über die Bemessung der FRAND-Lizenzgebühr und die dabei einzustellenden Umstände streiten, hat der Verletzte auch zur Vorbereitung eines Schadensersatzhöheprozesses nach der Methode der Lizenzanalogie ein berechtigtes Interesse, die geforderten Gewinnangaben zur Kenntnis zu bekommen. Denn in dieser Situation, in der die relevanten Umstände der Lizenzierung hochstreitig sind und die Gefahr der Festlegung einer unangemessen niedrigen oder hohen Lizenzgebühr besteht, kann die Erforderlichkeit von Gewinnangaben zur Beurteilung der FRAND-Grenzen und damit zur Vorbereitung eines Höheprozesses nicht ohne weiteres von vornherein verneint werden. Die über den Umfang nach § 140b Abs. 3 PatG hinausgehenden Angaben sind dem Verletzer in dieser Situation dann auch grundsätzlich zumutbar.

115 Da die Beklagte im vorliegenden Rechtsstreit nichts gegen die Antragsweite zur Auskunft / Rechnungslegung erinnert, kann die Kammer nach den vorstehenden Erwägungen Auskunft und Rechnungslegung im beantragten Umfang ohne weiteres zuerkennen.

V.

116 **derzeit unbegründete weitergehende Ansprüche**

117 Die Klage ist als derzeit unbegründet abzuweisen, soweit die Klägerin von der Beklagten Unterlassung, Rückruf und Entfernung aus den Vertriebswegen sowie die Vernichtung patentverletzender Produkte nach Art. 64 Abs. 3 EPÜ iVm. § 139 Abs. 1, § 140a

Abs. 1, Abs. 3 PatG begehrt. Einer gerichtlichen Durchsetzung dieser Ansprüche stehen kartellrechtliche Gründe - in Anwendung der Entscheidung des Unionsgerichtshofs in der Rechtssache Huawei./. ZTE (EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015 – C-170/13, GRUR 2015, 764 = ECLI:EU:C:2015:477 idF des Berichtigungsbeschlusses vom 15. Dezember 2015, ECLI:EU:C:2015:817) - als dilatorische Einwendung entgegen (vgl. auch OLG Düsseldorf aaO Rn. 221).

1.

118 Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand kann der Klägerin grundsätzlich entgegengehalten werden. Denn die Klägerin verfügt als Inhaberin des Klagepatents über eine marktbeherrschende Stellung und ist hiernach Normadressatin nach Art. 102 AEUV.

119 Die hierfür grundsätzlich darlegungs- und beweisbelastete Beklagte hat insoweit vorgetragen, dass ein Mobiltelefon, welches die Standardfestlegungen nicht umsetze, im aktuellen UMTS-Standard nicht mehr funktioniere, jedenfalls eine wesentliche Funktionalität für den mobilen Datenverkehr nicht bereitstelle, und dass für solche Mobiltelefone keine Aussicht auf nennenswerte Absatzerfolge mehr bestünden. Damit hat die Beklagte schlüssig aufgezeigt, dass die Nutzung des Klagepatents geradezu eine Marktzutrittsvoraussetzung begründet, womit der Klägerin eine marktbeherrschende Stellung zukommen kann. Die Klägerin hat hierauf lediglich vorgetragen, das die technische Lehre des Klagepatents voraussetzende HSUPA-Kommunikationsprotokoll sei nicht erforderlich, um UMTS-Mobiltelefone zu vermarkten, weil man heute nach wie vor „ohne diesen schnellen Uplink-Datenkanal auskommen“ könne. Angesichts der Implementierung des HSUPA-Schemas in UMTS sowie angesichts der von der Klägerin gegenüber der Standardisierungsorganisation deklarierten Standardessentialität des Klagepatents und der hiernach abgegebenen ETSI-FRAND-Erklärung unterliegt die Klägerin zumindest einer gesteigerten Substantiierungslast, der dieser klägerische Vortrag nicht genügt. Danach kann das Beklagtenvorbringen als unstreitig angenommen werden.

2.

120 Auf Grundlage der Entscheidung des Unionsgerichtshofs in der Rechtssache Huawei Technologies/ZTE kommt die Kammer - wie auch im parallelen Verletzungsrechtsstreit zwischen den Parteien zum Aktenzeichen 7 O 238/15 (dort Urteil vom 19. August 2016) - zum Schluss, dass die derzeitige Durchsetzung der auf das Klagepatent gestützten Ansprüche auf Unterlassung, Rückruf/Entfernung und Vernichtung als ungerechtfertigter Marktmachtmissbrauch nach Art. 102 AEUV zu bewerten ist, weil die Klägerin den sie treffenden FRAND-Verfahrensobliegenheiten bislang nicht hinreichend nachkommen ist.

a)

121 Das vom Unionsgerichtshof entwickelte Konzept stellt in erster Linie Anforderungen auf für ein faires Verfahren zwischen den Parteien, aufgrund dessen Lizenzverhandlungen auf Augenhöhe gewährleistet werden, an deren Ende eine Einigung über die Gesamtheit der Lizenzbedingungen im Sinne „FRAND“ erzielt werden kann (vgl. auch Haedicke, GRUR Int. 2017, 661, 662). Maßgeblich werden dem SEP-Patentinhaber dabei Informationsobliegenheiten auferlegt, die sicherstellen sollen, dass beide Parteien den gleichen Zugang zu Informationen haben, wodurch einer Ungleichgewichtslage der Parteien entgegengewirkt wird. Die Einhaltung oder Nichteinhaltung der FRAND-Verfahrensanforderungen ermöglicht es dem Verletzungsgericht letztlich, das Verhalten des Inhabers eines

SEP auf der einen Seite sowie eines (angeblichen) Verletzers auf der anderen Seite daraufhin zu bewerten, ob sich die Durchsetzung der auf das SEP gestützten Unterlassungs- und Rückrufanträge als ungerechtfertigter Marktmachtmissbrauch und Aufbau eines zu unterbindenden Drucks in der Verhandlungssituation oder als gerechtfertigte Reaktion auf eine vom Verletzer verfolgte Verzögerungstaktik darstellt.

aa)

122 Für ein faires Verfahren hält es der Gerichtshof zunächst für erforderlich, dass der Patentinhaber in einem ersten Schritt vor der Erhebung einer auf Rückruf und Unterlassung gerichteten Klage, die für den (angeblichen) Verletzer einen erheblichen Verhandlungsdruck aufbaut, jenen auf die ihm vorgeworfene Patentverletzung hinweist und dabei das SEP bezeichnet sowie angibt, auf welche Weise es verletzt sein soll. Durch den Hinweis muss der Verletzer in die Situation versetzt werden, die Schutzrechtslage selbständig prüfen zu können, ggf. unter Hinzuziehung externen oder internen technischen Sachverstands. Als grundsätzlich ausreichend zur Erfüllung der Hinweispflicht erachtet die Kammer weiterhin die auch im Rahmen von Lizenzvertragsverhandlungen nach den geschäftlichen Gepflogenheiten sonst üblichen Claim-Charts, die den geltend gemachten oder einen ihm verwandten Anspruch des Klagepatents, der gleichfalls die entscheidenden Merkmale aufweist, gegliedert nach Anspruchsmerkmalen den entsprechenden Stellen im Standard gegenüberstellt, ohne dass hierbei die Anforderungen der Schlüssigkeitsprüfung einer Verletzungsklage erfüllt werden müssten. Seiner Hinweispflicht kommt der SEP-Inhaber regelmäßig schon dann hinreichend nach, wenn die Hinweise gegenüber der Konzernmuttergesellschaft des (angeblichen) Verletzers erfolgen (vgl. im Einzelnen hierzu: OLG Düsseldorf aaO Rn. 146).

bb)

123 Hat der (angebliche) Verletzer oder dessen Muttergesellschaft auf den Verletzungshinweis im Grundsatz den Willen zum Ausdruck gebracht, überhaupt Lizenz nehmen zu wollen (zur Lizenzwilligkeit vgl. die umfangreiche Darstellung bei OLG Düsseldorf aaO Rn. 151 ff.), trifft den SEP-Patentinhaber die weitere Obliegenheit, dem (angeblichen) Patentverletzer ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten. Formal erfordert dies zum einen, dass die vertragswesentlichen Bedingungen enthalten sind, das Vertragsangebot also annahmefähig ist. Zum anderen ist der Angebotsempfänger in die Lage zu versetzen, anhand objektiver Kriterien nachzuvollziehen, warum das unterbreitete Angebot - bei objektivierter Betrachtung aus der Perspektive des Patentinhabers - FRAND-Kriterien entspricht. Hierfür sind insbesondere die Lizenzgebühr anzugeben und die Art und Weise ihrer Berechnung transparent zu machen, etwa durch Vortrag zu einem in der Vertragspraxis gelebten und von Dritten akzeptierten Standardlizenzprogramm oder unter Heranziehung anderer Bezugsgrößen, aus denen die geforderte Lizenzgebühr abgeleitet wird, bspw. aus einer Poollizenzgebühr, die in der Praxis für einen Patentpool von Dritten gezahlt wird, der auch für den fraglichen Standard relevante Patente umfasst. Der Umfang der gebotenen Darlegungen im Einzelfall wird dabei von der konkreten Lizenzierungssituation abhängen. Die bloße Mitteilung von Multiplikatoren, die der Berechnung der Lizenzgebühr zugrunde liegen, ist nach alledem nicht ausreichend, wenn es dem Angebotsempfänger anhand dieser Parameter noch nicht möglich ist zu beurteilen, ob das Angebot - innerhalb des zuzugestehenden Entscheidungsspielraums bei objektivierter Betrachtung - FRAND ist, und hierauf gegebenenfalls ein FRAND-Gegenangebot zu machen, weil es dem Lizenzsucher, wie der Gerichtshof aus-

führt, regelmäßig gerade an den hierzu benötigten Informationen über den Lizenzmarkt fehlt, über welche der SEP-Patentinhaber aber verfügt.

cc)

124 Die vorstehend angesprochenen Obliegenheiten des SEP-Patentinhaber, gerade auch das Gebot der transparenten Darlegung der Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühr, bestehen (im Grundsatz) jeweils vor Klageerhebung. Denn das vom Unionsgerichtshof entwickelte Konzept ist nach dem Verständnis der Kammer von der Intention getragen, dass sich der (angebliche) Verletzer, ohne dem Druck einer bereits erhobenen Unterlassungsklage ausgesetzt zu sein, im Verhandlungswege entscheiden kann, ob er gewillt ist, die vorgeschlagenen und transparent gemachten Vertragsbedingungen als FRAND entsprechend anzuerkennen und zu diesen Bedingungen Lizenz zu nehmen oder mit einem FRAND-Gegenangebot eine Einigung zwischen den Parteien anzustreben.

125 Die Kammer hat in ihrer bisherigen Rechtsprechung - so im Parallelverfahren 7 O 238/15 - eine Nachholung der an sich vorprozessual zu erfüllenden Obliegenheiten des SEP-Patentinhabers vor diesem Hintergrund nicht zugelassen. Ob an dieser Spruchpraxis festzuhalten ist, bedarf im konkreten Rechtsstreit keiner Entscheidung.

126 Angesichts des im Prozessrecht grundsätzlich allein maßgeblichen Zeitpunkts des Schlusses der letzten mündlichen Verhandlung für das Vorliegen der Sachurteilsvoraussetzungen und der die Begründetheit eines Leistungsklageantrags tragenden Tatsachen sowie angesichts des auch das Unionsrecht tragenden Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit (vgl. Art. 6 EUV iVm. Art. 52 Abs. 1 S. 2 GRCh) wird die Kammer aber zukünftig zu prüfen haben, ob der bislang eingenommene Standpunkt zur Wahrung der Vorgaben des Unionsgerichtshofs erforderlich ist. Um dem vom Gerichtshof konkretisierten Unionsrecht zur praktischen Wirksamkeit („effet utile“) zu verhelfen, wozu die Mitgliedstaaten und ihre Gerichte verpflichtet sind (Art. 4 Abs. 3 EUV), wird im Falle der Nachholung vorprozessual nicht erfüllter Obliegenheiten im Verlauf des Verletzungsrechtsstreits indes sicherzustellen sein, dass das Gebot vorprozessualer Erfüllung nicht sanktionslos unterlaufen werden kann und dass der Leitgedanke, Lizenzverhandlungen ohne den unmittelbaren Druck eines gerichtlichen Verfahrens auf Augenhöhe auf Grundlage entsprechender Informationen führen zu können, als möglich im Prozess verwirklicht wird. Die Kammer tendiert eingedenk dessen dazu, dass dem SEP-Patentinhaber, der seine vorprozessualen Obliegenheiten (erstmals) im Prozess nachzuholen gedenkt, obliegt eine „drucklose“ Verhandlungssituation mit dem (angeblichen) Verletzer wiederherzustellen. Eine solche Verhandlungslage bietet das Prozessrecht im Rahmen der Ruhendstellung eines Rechtsstreits zum Zwecke von (Vergleichs-)Verhandlungen nach § 251 ZPO iVm. § 249 Abs. 1, Abs. 2 ZPO. Hiernach dürfte der SEP-Patentinhaber bei Nachholung seiner Informationsobliegenheiten gehalten sein, das Ruhen des Verletzungsrechtsstreits zu beantragen. Der (angebliche) Verletzer wird sich in dieser Situation dem Ruhensantrag der klagenden Partei anschließen, wenn er lizenzwillig ist, um in „drucklose“ Lizenzverhandlungen zurückzukehren.

b)

127 Bei Zugrundelegung dieser Maßstäbe ist die Klägerin vorliegend aus kartellrechtlichen Gründen gehindert, die mit der Klage verfolgten weitergehenden Ansprüche durchzusetzen.

aa)

128 Die Klägerin hat ihre Obliegenheit vorprozessual nicht erfüllt, gegenüber der Beklagten transparent zu machen, aufgrund welcher Tatsachen sie den von ihr im Lizenzvertragsangebot geforderten Lizenzsatz - im Rahmen eines zuzugestehenden Entscheidungsspielraums - für FRAND hält. Sie hat sich vielmehr darauf beschränkt, in ihrem Angebot pauschal zu behaupten, dass die angemessene Lizenz USD […] bzw. USD […] pro Stück sei. Die bloße Angabe der Multiplikatoren ist - wie ausgeführt - nach Auffassung der Kammer nicht annähernd ausreichend, um die Vorgaben der Entscheidung des Unionsgerichtshofs zu erfüllen. Auch der pauschale Verweis auf weitere Lizenznehmer ohne nähere Erläuterung der Lizenzbedingungen sowie der gleichfalls pauschale Verweis auf das Portfolio von Z sowie ein nicht zugänglich gemachtes Sachverständigengutachten aus dem A-Verfahren haben die Beklagte vorprozessual nicht in die Lage versetzt, valide zu prüfen, ob das Angebot der Klägerin FRAND ist und nicht hinreichend plausibel gemacht, warum die Klägerin meint, der Auffassung sein zu dürfen, die von ihr geforderten Konditionen entsprächen FRAND.

bb)

129 Mit den weiteren, erstmals im Prozess gemachten Erläuterungen hat die Klägerin ihrer Informationsobliegenheit weiterhin nicht genügt. Soweit sich die Klägerin hierin maßgeblich auf das Privatgutachten von Prof. […] stützt und anführt, dieser habe die von der Klägerin abgeschlossenen Lizenzverträge einsehen können, weist die Beklagte in ihrem Schriftsatz vom 6. September 2016 (Bl. 316 d.A.) letztlich darauf hin, dass in diesem Gutachten und auch sonst im Klägervorbringen schon intersubjektiv nachvollziehbare Angaben zum Lizenzvertrag mit C fehlen.

130 Die Klägerin hat durch ihre Vertreter in der mündlichen Verhandlung im Parallelverfahren 7 O 238/15 - dies hat die Beklagte unwidersprochen vorgetragen - eingeräumt, dass der mit C abgeschlossene Lizenzvertrag auf einer Pauschalzahlung gründet, welche auch die künftige Nutzung des UMTS/LTE-Portfolios der Klägerin abdecke. Angesichts dieser Sachlage hat die Klägerin zumindest nicht transparent aufgezeigt, dass die in ihrem Angebot geforderte Lizenzgebührenhöhe auch FRAND unter dem Gesichtspunkt „non discriminatory“ ist. Aufgrund der mit C getroffenen Pauschalabgeltung kann vorliegend nicht ausgeschlossen werden, dass die C gewährten Konditionen erheblich günstiger sind als das Lizenzvertragsangebot gegenüber der Beklagten bzw. ihrer Muttergesellschaft und dass hiernach die Klägerin ihre Lizenznehmer / Lizenzsucher ohne sachliche Rechtfertigung ungleich behandelt. Die im Rahmen eines fairen Verfahrens der Klägerin obliegende transparente Erläuterung der Lizenzvertragsbedingungen zum Zwecke ihrer intersubjektiven Nachvollziehbarkeit als FRAND-gemäß erfordert bei einer solchen Sachlage jedenfalls weitergehende belastbare Angaben zu den konkreten anderweitig gewährten Lizenzbedingungen und den Sachgründen einer etwaigen Ungleichbehandlung der Lizenznehmer / Lizenzsucher. Dem SEP-Inhaber ist solches schon deshalb zumutbar und abzuverlangen, weil ihn im Hinblick auf das kartellrechtliche Diskriminierungsverbot nach Art. 102 Abs. 1, Abs. 2 lit. c AEUV ohnehin eine sekundäre Darlegungslast hinsichtlich einer Gleichbehandlung der Lizenzsucher und die (primäre) Darlegungs- und Beweislast für einen hinreichenden sachlichen Grund einer Ungleichbehandlung treffen (vgl. zur Darlegungs- und Beweislast: OLG Düsseldorf aaO Rn. 178). Der - nach dem unwidersprochen gebliebenen Vortrag der Beklagten - im Parallelverfahren erfolgte schlichte, nicht weiter konkretisierte Hinweis der Klägervertreter, die Klägerin habe bei der Vereinba-

rung der Pauschalzahlung die künftigen Absatzzahlen von C erheblich unterschätzt, genügt den Erfordernissen einer transparenten Erläuterung in keinem Fall.

cc)

131 Die Klägerin ist vorliegend auch nicht von dieser Obliegenheit entbunden, weil sich die Beklagte oder ihre Muttergesellschaft als lizenzunwillig gezeigt hätten. Selbst wenn im Zuge der Verhandlungen zwischen den Parteien vereinzelt eine Zahlung von Lizenzgebühren in einzelnen Aussagen gegenüber der Klägerin abgelehnt worden sein sollte, so hat sich die Verhandlungsgegenseite nach Auffassung der Kammer nicht grundsätzlich lizenzunwillig gezeigt, da sie in einer Vielzahl von Treffen einen möglichen Lizenzvertrag diskutiert hat. Zudem ist aus Sicht der Kammer zu berücksichtigen, dass die Beklagte bzw. ihre Muttergesellschaft – wenngleich erst nach Klageerhebung – ein Gegenangebot unterbreitet und einen namhaften Betrag hinterlegt hat, der nahezu das Dreifache des Betrages abdeckt, der sich auf der Grundlage der gleichfalls geleisteten Rechnungslegung und des Gegenangebots ergibt. Zwar liegen diese Umstände nach Klageerhebung, indes wertet die Kammer dieses Verhalten als Indiz auch für die grundsätzliche Lizenzwilligkeit jedenfalls in einem solchen Maße, dass die nähere Erläuterung der kaufmännischen Bedingungen, hier insbesondere der Höhe der verlangten Lizenzgebühr nicht obsolet gewesen wäre. Denn das Gesamtverhalten der Beklagten und ihrer Muttergesellschaft lässt nicht den Schluss zu, es handele sich um einen von vornherein lizenzunwilligen Verhandlungspartner, dem gegenüber keine Verpflichtung besteht darzulegen, aus welchen tatsächlichen Gründen die Angebote des SEP-Patentinhabers FRAND-Grundsätzen entsprechen.

VI.

132 **keine Aussetzung**

133 Die von der Beklagten erhobene Nichtigkeitsklage gegen das Klagepatent gebietet trotz Vorgreiflichkeit keine nach § 148 ZPO ins Ermessen der Kammer gestellte Aussetzung des Verletzungsrechtsstreits. Hierbei lässt sich die Kammer von folgenden Erwägungen leiten.

1.

134 Die Aussetzungsentscheidung erfordert eine Abwägung des mit dem Interesse der beklagten Partei übereinstimmenden Interesses an widerspruchsfreien Entscheidungen im Verletzungs- und Rechtsbestandsverfahren gegenüber dem Interesse des Verletzungsklägers an einem zeitnahen Abschluss des Verletzungsverfahrens (vgl. BGHZ 158, 372, 376 - Druckmaschinen-Temperiersystem I). Da der Verletzungsrichter an den Erteilungsakt gebunden ist, kommt eine Suspendierung der aus dem erteilten Patent folgenden Ausschließlichkeitsbefugnisse nur unter besonderen Umständen in Betracht. Regelmäßig erforderlich, aber zur Gewährung effektiven Rechtsschutzes für den Verletzungsbeklagten auch genügend ist es, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass das Klagepatent dem erhobenen Rechtsbestandsangriff nicht standhalten wird (vgl. BGH, GRUR 2014, 1237, 1238 - Kurznachrichten). Soweit - wie vorliegend - nur (noch) finanzielle Ausgleichs- und korrespondierende Auskunfts-/Rechnungslegungsansprüche zur Entscheidung stehen, ist es zwar gerechtfertigt, das Durchsetzungsinteresse des Klägers geringer zu bewerten und danach einen herabgesetzten Aussetzungsmaßstab anzusetzen. Jedoch muss auch dann dem ergriffenen Rechtsbehelf einige Erfolgsaussicht zu-

kommen (vgl. BGH, GRUR 1987, 284 - Transportfahrzeug). Dies erfordert zumindest eine gewisse Wahrscheinlichkeit des Erfolgs des Nichtigkeitsangriffs; die bloße Möglichkeit, dass das Klagepatent vernichtet wird, ist auch dann nicht ausreichend.

2.

135 Gemessen an diesem Maßstab hat es die Beklagte nicht vermocht, der nicht fachmännisch besetzten Kammer aufzuzeigen, dass zumindest eine gewisse Wahrscheinlichkeit des Erfolgs ihrer Nichtigkeitsklage besteht, insbesondere in Bezug auf eine Beurteilung der Entgegenhaltung D1 als neuheitsschädliche Vorwegnahme der technischen Lehre des Klagepatents. Auch unter Berücksichtigung der Entscheidung der Rechtbank Den Haag vom 22. März 2017 zum niederländischen Teil des hier interessierenden europäischen Patents EP 1 623 511 ist der Kammer nicht glaubhaft gemacht, dass der Fachmann im Prioritätszeitpunkt dem Offenbarungsgehalt der D1 unmittelbar und eindeutig das Merkmal c.2 entnehmen konnte. Nach dem Vorbringen der Parteien kann die Kammer schon nicht feststellen, dass nach dem maßgeblichen Verständnis des Fachmanns die Rückanpassung der Sendeleistung entsprechend dem von der Beklagten in Bezug genommenen Abschn. 2.1.2.3.2 der D1 überhaupt innerhalb des Frames - also „innerhalb der vorgegebenen Zeitspanne“ - zu erfolgen hat. Damit ist ein Erfolg der Nichtigkeitsklage bei einer Prognosebetrachtung aus Sicht der Kammer allenfalls möglich, nicht aber wahrscheinlich.

VII.

136 **Nebenentscheidungen**

137 Die Nebenentscheidungen zu Kosten und vorläufiger Vollstreckbarkeit folgen aus § 92 Abs. 1, § 709 ZPO. Hinsichtlich der Beurteilung des Verhältnisses des Obsiegens und Unterliegens der Parteien hat die Kammer die geltend gemachten Ansprüche im Verhältnis zueinander bewertet und dabei berücksichtigt, dass das Klagepatent eine Restlaufzeit von noch gut acht Jahren hat, die vergangenheitsbezogenen und zuerkannten Ansprüche aber bereits einen Zeitraum von gut 10 Jahren abdecken und der Urteilsausspruch insoweit auch in die Zukunft gerichtet ist, soweit die Beklagte mit den patentverletzenden Handlungen fortfährt (vgl. hierzu BGH, GRUR 2004, 755 - Taxol). Danach sind die Kosten gegeneinander aufzuheben.

Fußnoten

1) „When someone, as representative, has performed a juridical act in the name of another person without having the authority to represent him in this way, then this other person may ratify that juridical act and, with that, give it the same legal effects as when it would have been performed on the basis of an adequate authority for representation.“